

0005407-21.2017.8.26.0283

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Christiano Melo

Comarca: Itirapina

Foro: Foro de Itirapina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

Cabe lembrar que o crime de tráfico é de ação múltipla, e se consuma com qualquer uma das práticas prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente de qualquer consequência ulterior ou da efetiva venda do entorpecente.

Imperiosa, pois, a condenação de todos os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Deste modo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itirapina

Foro de Itirapina

Vara Única

Rua 01, nº 180, Itirapina - SP - cep 13530-000

0005407-21.2017.8.26.0283 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005407-21.2017.8.26.0283

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON RODOLFO RODRIGUES, MATEUS RODRIGUES FRANCISCO e PAULO SERGIO DESTEFANI FILHO

Juiz de Direito: Dr. Leonardo Christiano Melo

I - Relatório

Trata-se de ação penal promovida em face de EVERTON RODOLFO RODRIGUES, vulgo "Ton", MATEUS RODRIGUES FRANCISCO, vulgo "Cabeça" e PAULO SÉRGIO DESTEFANI FILHO, vulgo "Paulinho de Sanca ou Paulinho do Verde", como incursos nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. 29 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do diploma repressivo. Segundo consta da denúncia, em data incerta, mas que perdurou até o dia 26 de setembro de 2017, em local incerto, EVERTON, MATEUS e PAULO SÉRGIO associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como porque, no dia 26 de setembro de 2017, por volta das 21hs50min, na Rodovia SP 310, Km 217, neste Município e Comarca de Itirapina, previamente associados, EVERTON e MATEUS, transportavam, após terem adquirido de PAULO SÉRGIO, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 03 invólucros de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido de 992,2 gramas, substância entorpecente, causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 27 e laudo toxicológico definitivo de fls. 95/96).

O processamento da denúncia foi deferido (fls. 307/308).

Os acusados Everton e Mateus foram notificados (fls. 336 e 342), e apresentaram

defesas prévias (fls. 333/334 e fls. 351/355).

O acusado Paulo Sérgio foi inicialmente notificado por edital (fls. 405/406). Na sequência constituiu defensores, comparecendo espontaneamente ao processo e apresentando defesa prévia (fls. 405/406).

A denúncia foi recebida em 14/09/2021 (fls. 424/429) e os acusados foram citados (fls. 556, 629, 668).

Em instrução, foi procedida a oitiva das testemunhas e interrogados os acusados (fls. 689/691).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do feito, com a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia (fls. 703/712).

A Defesa do acusado Everton Rodolfo Rodrigues pugnou pela absolvição pela inexistência de provas suficientes para a condenação (artigo 386, inciso IV do CPP e artigo 25 do CP). Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de uso de entorpecente, fixando-se a pena base no mínimo legal. Em caso de condenação requereu a fixação da pena abaixo do mínimo legal, além do reconhecimento das atenuantes legais. Requereu que a pena de multa guarde a proporcionalidade com a pena corporal imposta, sendo fixada em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos. Por fim, requereu a substituição de eventual pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, além da pena pecuniária a ser fixada, e regime inicial aberto (fls. 716/721).

A Defesa do acusado Mateus Rodrigues Francisco requereu a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a imposição de regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 725/730).

A Defesa do acusado Paulo Sérgio Destefani Filho preliminarmente pugnou pela inépcia da inicial, por grave omissão quanto à descrição dos fatos típicos. No mérito, pugnou pela nulidade da prova obtida por meio ilícito, sustentando que não houve autorização judicial para acesso às mensagens relativas ao WhatsApp referentes ao celular do acusado. No mais, requereu a absolvição pela negativa de autoria e inexistência de crime (art. 386, inciso VI, do CPP), argumentando que inexistem provas da mercância ilícita, tampouco da associação (fls. 733/741).

É o relatório. DECIDO.

## II - Fundamentação

A ação é parcialmente procedente.

Com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, é o caso de se absolver todos os acusados.

No tocante ao crime de tráfico, a materialidade e autoria com relação a todos os acusados restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 24/29), auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 100/102), Relatório de Investigações (fls. 47/48), pelas conversas degradadas nos autos (fls. 52/88), bem como pela prova oral colhida em instrução.

A testemunha Rodrigo Franco, policial militar rodoviário, declarou que na data dos fatos estavam efetuando patrulhamento de rotina direcionado ao tráfico de drogas. Realizada a abordagem do veículo ocupado pelos réus verificou-se que Everton era o condutor e Mateus o passageiro. Antes de verificar o veículo foi possível sentir odor característico de maconha. Revistado o veículo foram localizados tijolos de maconha atrás do banco do motorista. Não se recorda a quantidade exata, porém se tratava de uma quantidade grande de droga, em dois tijolos. Entrevistados os acusados afirmaram que vinham da cidade de São Carlos onde adquiriam o entorpecente e se dirigiam até a cidade de Brotas. Negaram que a droga se destinasse à venda, contudo, disseram que seria dividida entre ambos e, posteriormente, a distribuiriam para as namoradas e amigos.

A testemunha José Wilson Abdo Della Valle, policial militar rodoviário, corroborou o depoimento de seu parceiro de farda e acrescentou que inicialmente o condutor do veículo, Everton, disse que voltava de uma academia em São Carlos, posteriormente admitiu que levou Mateus para comprar drogas naquela cidade. Mateus, por seu turno,

disse que a droga era sua e posteriormente iria dividi-la com Everton e distribuir para amigos e para a namorada em Brotas. Afirmou ainda que o que motivou a abordagem foi o fato de o veículo ter feito movimento de “zigue-zague” e o nervosismo apresentado pelos acusados. Por fim, disse que havia odor característicos de maconha no veículo e que a quantidade de droga encontrada foi grande.

A testemunha de defesa José Roberto Correa declarou que desconhece qualquer fato que desabone a conduta do réu Everton e que se trata de pessoa trabalhadora.

A testemunha de defesa Matheus Coró disse que é amigo de infância de Everton e desconhece qualquer envolvimento dele com tráfico de drogas, entretanto, afirmou que adquiriam drogas para consumo pessoal.

A testemunha de defesa Maria Célia Pereira Rodrigues, mãe de Everton, disse que o filho sempre trabalhou e foi responsável. Na ocasião dos fatos acreditava que ele necessitava de internação para tratamento de drogas, entretanto, disse que ele levava uma vida normal, trabalhava e se relacionava socialmente e que jamais se submeteu a qualquer tratamento.

A testemunha de defesa Maria Eduarda Rodrigues, esposa de Paulo, disse que desconhece quaisquer mensagens relacionadas ao tráfico de drogas no celular de seu marido. Reconheceu como sendo o número de Paulo aquele indicado à fl. 72, que estava salvo nos contatos dos acusados Everton e Mateus.

A testemunha de defesa Marcelo Nascimento declarou que conhece Paulo desde a infância e desconhece qualquer fato que desabone sua conduta.

A testemunha de defesa Eliana Maria Pereira disse que nada sabe que desabone a conduta de Paulo.

A testemunha de defesa Derik Zeferino Souza disse que já trabalhou com Paulo. Disse que pode assegurar que na data dos fatos Paulo estava trabalhando e nada sabe que desabone sua conduta.

A testemunha de defesa Gabriel Pessa declarou que conhece Mateus. Sabe que é usuário de drogas, mas é bastante trabalhador. Nada sabe que desabone sua conduta. O réu Mateus Rodrigues Francisco declarou que confirma o teor das conversas contidas no seu celular e degravadas nos autos. Disse que, entretanto, não conhece “Paulinho”, portanto, não tem certeza se “Paulinho” é o réu Paulo, já que nunca o viu pessoalmente. Disse que comprava drogas de “Paulinho”, mas as entregas eram realizadas por motoboy e não mantinha contato nem mesmo com o motoboy. Disse que na delegacia lhe foram apresentadas fotos, mas não tinha condições de reconhecer “Paulinho”. Disse que a droga apreendida no dia dos fatos era sua e de Everton, metade de cada um. Exibida a imagem de uma conversa constante às fls. 74/75 disse que não se recorda da conversa, embora afirme que possuía o contato “Paulinho Verde”. Disse que comprava drogas para seu consumo e negou que comprasse drogas para outras pessoas. Afirmou que tudo correu bem em seu depoimento na delegacia, porém para tentar “se livrar” da situação disse que comprava as drogas para distribuir para outras pessoas.

Em seu interrogatório Everton disse que na data dos fatos foi com Mateus para São Carlos para comprar maconha, entretanto, afirmou que a droga era para consumo de ambos. Disse que foi mais de uma vez com Mateus para São Carlos para comprarem drogas, mas disse que nem sempre compravam de Paulo. Afirmou que possivelmente comprou drogas de Paulinho uma única vez. Na data dos fatos compraram drogas de Paulinho, a negociação foi feita de forma pretérita e o pagamento se deu possivelmente por meio de depósito bancário. Reconhece as conversas degravadas nos autos, mas negou ter vendido ou entregado drogas para terceiros.

Em seu interrogatório Paulo disse que o telefone 16- 99713-9908 (dos autos) era seu número na época dos fatos. Além do número reconheceu a fotografia de fl. 68 como sendo sua. Disse que nunca teve problemas com sua linha telefônica, tampouco teve problemas com seu nome. Disse que em meados de 2019 resolveu trocar o número de telefone, embora o usasse também para fins comerciais, sem declinar maiores motivos para a troca.

Pois bem.

O conjunto probatório amealhado aos autos não deixa dúvidas da prática do crime de tráfico por todos os acusados.

Em que pese todos os acusados tenham negado veementemente a prática dos crimes em juízo, as mensagens extraídas dos aparelhos de telefonia celular apreendidos (fls. 52/88) aliados à prova oral coligida, bem como às circunstâncias em que se deu a apreensão da grande quantidade de drogas em poder dos acusados, denotam a exploração do tráfico.

No relatório de investigação nº 155/17 elaborado pela Polícia Civil da Delegacia de Polícia de Itirapina constou o seguinte (fls. 47/48):

"Após levantamentos realizados nos aparelhos celulares apreendidos no RDO n. 928/17 (IP n. 155/2017) conforme previa autorizado judicial deferida no processo n. 00005542-33.2017.8.26.0283, verificou-se que:

1) EVERTON RODOLFO RODRIGES "TOM" mantém contato através do Telegram com BURCA onde fazem tratativas a respeito da compra e venda de entorpecente no atacado, ocasião em que BURCA indaga EVERTON (TOM) quanto estão pagando da mercadoria e tem como resposta R\$ 2.200,00 mais viagem e então BURCA oferece por R\$ 1.700,00 do verde e EVERTON (TOM) afirma que deve aguardar o cabecinha (apelido do indiciado MATHEUS) dizendo que é ele quem tem os clientes.

2) No dia da apreensão do entorpecente (26/09/2017) EVERTON "TOM" efetuou ligações telefônicas 19:54 horas e 20:58 horas para PAULINHO DE SANCA - 16- 997139908, e pelas conversas entre os indiciados e obtidas do aparelho do indiciado MATHEUS no dia anterior, ou seja, 25/09 verifica-se que o entorpecente foi adquirido de PAULINHO DE SANCA pois EVERTON (TOM) diz "mandei mensagem para Paulinho esculachando, mano se ta tirando, esta com dois conto nosso e não responde nada.....Paulinho mandou mensagem dizendo que a mãe e irmã sofreu acidente mas que amanhã ta na mão, para nos ir amanhã que ta na mão."

3) Verificou-se ainda no aparelho celular de MATHEUS (cabeça) que ele conversa com EVERTON (TOM) desde 02/02/2017 onde passa contato de PAULINHO DE SANCA. O próprio MATHEUS tinha contato com PAULINHO DE SANCA, contato por ele salvo como PAULINHO DO VERDE e se confirma nas mensagens o tráfico onde PAULINHO diz "man deixa fala foda q fazer menos não consigo pq eu vou ter quase isso soh e soltar por menos deixo de ganha uma grana alta... Q soltar a 4p 1 ta ligado.... Em meia o que da pra fazer eh 1.350 man desconta 150 conto man... se não eu não ganho nada ja nao to ganhando igual se eu soltasse a 4p 1 essas meia". (...)"

Prosseguindo, passo à análise dos dados contidos nos celulares apreendidos com os acusados, vez que após a obtenção de autorização judicial, a Autoridade Policial teve acesso às mensagens que neles constavam.

Conforme destacado pelo Ministério Público, nas mensagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos acusados Everton e Mateus há menção específica à compra e venda de entorpecentes e negociação em dinheiro, inclusive com relação Paulo:

a) na conversa de fl. 66 entre Mateus e Everton, este discutem se devem comprar drogas pelo valor de R\$ 2.300,00. Na mesma conversa, Everton afirma que é "o frente" de Brotas. Em especial, à fl. 73, Paulo se desculpa por ter atrasado uma entrega, oferecendo 50 gramas de "maconha" como forma de compensação. Na continuação, Paulo pergunta à Mateus se deve encomendar entorpecentes pelo valor de R\$ 1.200,00;

b) na conversa de fl. 73, Paulo informa que só tem 50 gramas de entorpecentes, mas que em breve iria chegar mais. Na sequência, Paulo manda uma foto de um tablete de maconha, informa que ela é R\$ 50,00 mais caro do que havia informado anteriormente, e pergunta à Everton se ele quer encomendar (fl. 74);

c) nas conversas de fls. 75/77 os acusados negociam a compra e venda de entorpecentes, sendo que, em especial à fl. 77, Paulo informa que não consegue fazer um preço melhor, caso contrário deixa de lucrar. No fim, acertam 500 gramas por R\$ 1.350,00. Conversas semelhantes ainda ocorrem às fls. 78/83;

d) nas conversas de fl. 84, Everton e Mateus combinam expressamente de irem à São Carlos comprar maconha, ocasião em que Everton afirma ter comprado "uma maconha de qualidade" de Paulo;

e) na conversa degravada do Telegram de Everton, a fl. 86, verifica-se o contato com indivíduo desconhecido de vulgo "Burca", onde o réu afirma que paga R\$ 2.200,00

mais o valor da viagem para buscar entorpecentes em outra cidade, ao passo que o interlocutor negocia, pretendendo que o acusado passe a ser seu comprador. Na ocasião assume que quer fazer negócio com os réus e diz que a maconha custa R\$ 1.700,00.

Passo à análise das mensagens extraídas dos celulares com relação à associação para o tráfico.

A fls. 52/53, observo que o acusado Mateus oferece entorpecentes para três pessoas, em 15/12/2016, 20/01/2017 e 31/03/2017. Nas mensagens constam valores, demonstrando que se trava de venda.

A fl. 57, em 23/02/2017 Mateus diz para "Tom" que vendeu mais "doce" e pediu para tentar pegar o "meio". Na sequência escreveu "Tem uma galera querendo", ao que "Tom" respondeu "Pode cre", "viu pega o meio".

A fl. 58 o acusado Mateus pergunta se "Tom" tem 50g, dizendo que o "quarque" quer, ao que "Tom" responde "manda vim pegar", em 25/02/2017.

A fl. 55 o acusado Mateus comenta com "Paulinho Verde", em 17/03/2017, que o outro entorpecente, que foi pego por "Tom", era melhor. Extraí-se, pois, que ao menos duas negociações foram feitas naquela época. Uma por "Tom" e outra por Mateus, tendo o mesmo fornecedor, o acusado Paulo.

Posteriormente não foram identificadas outras aquisições de drogas pelos acusados por meio de mensagens, o que somente voltou a ocorrer na véspera da prisão em flagrante, que se deu em 26/09/2017.

Especificamente sobre o fornecimento das drogas pelo acusado Paulo, observo que constam as negociações acima referidas, tratadas por mensagens e ligações telefônicas diretamente com os acusados Everton e Mateus, na época citada (fls. 72/82).

Conforme constou no relatório de investigação nº 155/17, elaborado pela Polícia Civil da Delegacia de Polícia de Itirapina (fls. 47/48), "no dia da apreensão do entorpecente (26/09/2017) EVERTON "TOM" efetuou ligações telefônicas 19:54 horas e 20:58 horas para PAULINHO DE SANCA - 16- 997139908, e pelas conversas entre os indiciados e obtidas do aparelho do indiciado MATHEUS no dia anterior, ou seja, 25/09 verifica-se que o entorpecente foi adquirido de PAULINHO DE SANCA pois EVERTON (TOM) diz "mandei mensagem para Paulinho esculachando, mano se ta tirando, esta com dois conto nosso e não responde nada.....Paulinho mandou mensagem dizendo que a mãe e irmã sofreu acidente mas que amanhã ta na mão, para nos ir amanhã que ta na mão."

Postas tais premissas, restou cabalmente comprovado nos autos que todos os acusados se conheciam e trocavam mensagens entre si.

Em que pese a negativa de Paulo, o número de seu aparelho celular estava salvo tanto nos contatos do acusado Mateus quanto do acusado Everton.

Em juízo o acusado Paulo confirmou que o número salvo nos contatos de Everton e Mateus lhe pertencia até meados de 2019, e reconheceu a própria fotografia (fl. 68) salva no contato do celular de Everton.

A esposa do acusado Paulo, em juízo também reconheceu como sendo o número de Paulo aquele indicado à fl. 72, que estava salvo nos contatos dos acusados Everton e Mateus.

Conforme ponderado pelo Ministério Público, o acusado Paulo, como já dito, manteve o número de celular até meados de 2019 quando alterou sua linha, afirmando que nunca teve problemas com qualquer operadora de celular ou relativamente ao uso indevido de seus dados. Causa estranheza que o acusado tenha efetuado a troca de linha telefônica apenas após tomar conhecimento da existência desta ação penal e o tenha feito sem qualquer outra motivação, uma vez que, como afirmou, fazia uso profissional da linha telefônica.

Isto posto, apesar das negativas, o acusado Paulo é, sem sombra de dúvidas, "Paulinho de Sanca" ou "Paulinho do Verde", que efetuou a venda/fornecimento de entorpecentes para os acusados Everton e Mateus não só no dia dos fatos, mas em ao menos outras duas oportunidades, anteriores a 26 de setembro de 2017.

E para que não haja qualquer dúvida, corroborando o teor das mensagens e as ligações telefônicas, em juízo o acusado Everton disse que foi mais de uma vez com Mateus para São Carlos para comprarem drogas, mas nem sempre comprovam de Paulinho.

Afirmou que possivelmente comprou drogas de Paulinho uma única vez. Na data dos fatos compraram drogas de Paulinho, a negociação foi feita de forma pretérita e o pagamento se deu possivelmente por meio de depósito bancário.

Assim, respeitado o entendimento Ministerial, analisando detidamente o conjunto probatório amealhado aos autos, entendo que é o caso de se absolver todos os acusados com relação à prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, eis que não restou provada à exaustão a propalada associação criminosa.

Destaco que não foi produzida qualquer prova no tocante à estabilidade dos acusados para a prática do crime de tráfico.

Neste específico ponto, destaco que somente foram comprovadas nos autos três aquisições de drogas do acusado Paulo, em datas esporádicas, entre fevereiro, março e setembro do ano de 2017.

No tocante à venda de drogas pelos acusados Mateus e Everton, tal qual já consignado acima, a fls. 52/53, o acusado Mateus oferece entorpecentes para três pessoas, em 15/12/2016, 20/01/2017 e 31/03/2017.

Nas mensagens constam valores, demonstrando que se trava de venda.

A fl. 57, em 23/02/2017 Mateus diz para "Tom" que vendeu mais "doce" e pediu para tentar pegar o "meio". Na sequência escreveu "Tem uma galera querendo", ao que "Tom" respondeu "Pode cre", "viu pega o meio".

A fl. 58 o acusado Mateus pergunta se "Tom" tem 50g, dizendo que o "quarque" quer, ao que "Tom" responde "manda vim pegar", em 25/02/2017.

Assim, as vendas de entorpecentes por Mateus e Everton também ocorreram pouquíssimas vezes, em datas também esporádicas, pelo menos de acordo com os elementos que foram juntados ao processo.

Deste modo, não se descarta totalmente que os acusados estivessem associados para prática reiterada do delito, entretanto, ao que parece neste caso específico tratou-se de um concurso de pessoas eventual.

Observo que o crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, distingue-se do concurso eventual de pessoas, que exige um acordo de vontades ocasional e efêmero para a perpetração de determinado crime; a associação pressupõe ajuste permanente e estável.

Nesse sentido, Vicente Greco Filho assevera que "para configurar o crime, é necessária a comprovação de que duas ou mais pessoas estão associadas para o fim de traficar. Não bastam suposições; é imprescindível apontar os elementos identificadores da vinculação subjetiva entre os agentes, seu ânimo de permanência e estabilidade da sociedade criminosa". Assim, se duas ou mais pessoas são presas "com certa quantidade de droga e não há absolutamente nenhum elemento de prova que possa indicar a 'affectio societatis', não se pode falar em associação ao art. 35" (GRECO FILHO, Vicente. Nova Lei de Drogas – Crimes, Investigação e Processo. 2 ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2012, p. 97/98).

Não por outro motivo, o Eg. STJ vem entendendo que "o tipo previsto no artigo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos art. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo" (REsp 1113728/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009).

No caso em análise não há provas de que os réus mantivessem associação estável e firme, com divisão de tarefas e atribuições minimamente definidas.

Certamente, a prova desse fato, por se relacionar à própria essência do tipo penal, cabia à acusação. Se ausente, ou, ainda, se insuficiente para ilidir a dúvida, a absolvição é imperiosa, na mais básica aplicação do adágio do in dubio pro reo, agora invocado.

Indo adiante, no tocante ao crime de tráfico, a expressiva quantidade de "maconha" (03 invólucros de maconha, pesando 992,2 gramas), a forma de acondicionamento (tijolos) e o modo da apreensão e as mensagens degravadas, evidenciam o propósito da traficância.

Não convence ainda as alegações de Everton e Mateus de que adquiriram os entorpecentes para uso pessoal.

Não bastasse a quantidade de "maconha" (quase um quilo) se mostrar desproporcional ao mero uso, ainda que de duas pessoas, as conversas degravadas nos autos, cuja autoria é incontroversa, já que confessada pelos acusados, demonstra de forma cristalina que os réus faziam a distribuição de entorpecentes a terceiros. Evidentemente não se nega a possibilidade de serem também usuários, aliás, a prática é comum. Muitos usuários fazem do tráfico o meio para obtenção da droga ou enquanto adquirem drogas para o próprio consumo, também o fazem para obtenção de lucro fácil, com o comércio a terceiros.

Na fase inquisitorial o acusado Mateus declarou o seguinte: "SOMENTE FUI À CIDADE DE SÃO CARLOS PARA COMPRAR A DROGA POIS O PREÇO ESTAVA MUITO BOM. E PAGUEI PELA DROGA A QUANTIA DE R\$ 600,00. QUE O RAPAZ DE QUEM EU COMPREI A DROGA O CONHECI NA FACULDADE UNICEP MAS NÃO SEI DIZER NOME E JÁ APAGUEI A CONVERSA QUE EU TIVE COM ELE NO WHATAPP. QUE PARA A COMPRA DA DROGA EU CONVIDEI MEU AMIGO EVERTON PARA ME LEVAR ATÉ O SHOPPING DE SÃO CARLOS ONDE PEGUEI A DROGA. QUE EVERTON SABIA DA COMPRA MAS A DROGA ERA MINHA E DEPOIS IRIA DAR UMA PARTE PARA ELE COMO PAGAMENTO DO TRANSPORTE. QUE A DROGA IRIA DISTRIBUIR PARA UMA GALERA DA CIDADE DE BROTAS. QUE É GALERA MAIS QUE FICA EM CASA NÃO GOSTA DE SAIR A NOITE. QUE NUNCA HAVIA COMPRADO DROGA COM O RAPAZ EMBORA JÁ CONHECI PESSOAS QUE COMPRARAM DELE. QUE NA CIDADE DE BROTAS EU NÃO IRIA VENDER A DROGA E APENAS IRIA DAR PARA CONHECIDOS. QUE ESTOU ARREPENDIDO DO ATO PRATICADO" (fls. 06/07).

Perante a Autoridade Policial o acusado Everton Rodolfo Rodrigues optou por permanecer em silêncio (fl. 16).

O depoimento do acusado na fase inquisitorial, embora não possa ser utilizado em juízo de forma exclusiva para eventual condenação, se encontra em total consonância com os depoimentos dos policiais, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, além dos demais elementos de prova coligidos aos autos, principalmente pela apreensão das drogas e armas no caminhão por ele conduzido.

Nesse sentido o art. 155 do Código de Processo Penal:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)"

Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. TESE DE QUE A CONDENAÇÃO FOI BASEADA APENAS NA PROVA INQUISITORIAL DEVIDAMENTE AFASTADA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que o entendimento da Corte a quo está em harmonia com a jurisprudência dos Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que não há ilegalidade quando, tal como ocorre na hipótese dos autos, a condenação está calcada em provas colhidas na fase extrajudicial, confirmadas em juízo. E para se acolher a pretendida absolvição, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 3. Outrossim, não merece reparos a fundamentação usada para majorar as penas-base, pois cabível a desvalorização das circunstâncias e consequências do crime quanto aos Pacientes diante da gravidade concreta dos delitos. Como após o trânsito em julgado a individualização da pena não é matéria de competência desta Corte Superior de Justiça, a matéria deve ser submetida à apreciação do Tribunal a quo,

pela via cabível da revisão criminal. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 603302 AL 2020/0196197-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020)".

Conforme jurisprudência pacificada, o depoimento de agentes de segurança, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF HC n. 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Nessa linha também: "[...] 3. Não há como afastar a credibilidade dos depoimentos de policiais prestados em juízo, que, juntamente com outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, foram utilizados para corroborar o acervo fático-probatório e fundamentar a condenação. Precedentes." (REsp 1302515/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Prosseguindo, a tese defensiva de ilicitude da prova obtida por meio dos aparelhos telefônicos não deve prevalecer.

Os aparelhos celulares dos acusados Everton e Mateus foram apreendidos pelos policiais após suas regulares prisões em flagrante e na sequência foi proferida decisão judicial (fls. 49/51), na qual foi deferida a quebra de sigilo das comunicações telefônicas dos celulares apreendidos, autorizando a degravação das respectivas conversas.

Em seguida, foi constatada a existência de mensagens e ligações envolvendo o corréu Paulo, que posteriormente foi identificado e, em juízo, foi confirmada a utilização daquele número de celular na época dos fatos. Não há o que se falar, pois, em prova ilícita.

Destaco que constitui dever da autoridade policial proceder à apreensão dos objetos indispensáveis à elucidação do crime e que as informações neles contidas, então, não só podem, como devem ser aproveitadas, ex vi do artigo 6º, incisos II e III e artigo 158 do Código de Processo Penal, sendo dispensável, nesse caso, prévia autorização judicial.

Isso porque, respeitado o entendimento da Defesa, a leitura das mensagens de texto armazenadas em aparelho celular apreendido após regular prisão em flagrante é procedimento que em nada se assemelha à interceptação telefônica regulada pela Lei nº 9.296/96.

Nesta última, certamente, há o monitoramento em tempo real das chamadas e mensagens, sem o conhecimento do acusado, para a elucidação de um possível crime. Naquela, por outro lado, há a simples averiguação de um objeto já apreendido, com o conhecimento do acusado, com o acesso a dados e mensagens pretéritos, já enviadas ou recebidas e que só permaneceram na memória do telefone por desídia do seu proprietário em apaga-los.

Outro não é, consigo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, respectivamente:

"O fato de ter sido verificado o registro das últimas chamadas efetuadas e recebidas pelos dois celulares apreendidos em poder do co-réu, cujos registros se encontravam gravados nos próprios aparelhos, não configura quebra do sigilo telefônico, pois não houve requerimento à empresa responsável pelas linhas telefônicas, no tocante à lista geral das chamadas originadas e recebidas, tampouco conhecimento do conteúdo das conversas efetuadas por meio destas linhas. Ademais, consoante o disposto no art. 6, incisos II e III, do Código de Processo Penal, é dever da autoridade policial apreender os objetos que tiverem relação com o fato, o que, no presente caso, significava saber se os dados constantes da agenda dos aparelhos celulares teriam alguma relação com a ocorrência investigada" (HC 66368; Rel. Min. Gilson Dipp).

"Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever



da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação." (HC 91867; Rel. Min. Gilmar Mendes).

E também o Eg. TJ/SP, em caso análogo:

"Habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Trancamento do inquérito policial, em virtude da ilicitude da prova, a teor do artigo 157, § 1º, do CPP. Inadmissibilidade. A consulta feita por policiais das últimas mensagens de texto recebidas pelo paciente em seu celular não representa quebra de sigilo telefônico, pois não houve acesso às conversas telefônicas realizadas, mas sim simples verificação de registro gravado no próprio aparelho. Precedentes Tribunais Superiores. [...]" (Relator(a): Diniz Fernando; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 24/11/2014; Data de registro: 27/11/2014).

Superada essa questão, o intuito da traficância também foi satisfatoriamente demonstrado, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, sua forma de acondicionamento, bem como pela forma que se deu a apreensão.

A jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância.

Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

Cabe lembrar que o crime de tráfico é de ação múltipla, e se consuma com qualquer uma das práticas prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente de qualquer consequência ulterior ou da efetiva venda do entorpecente.

Imperiosa, pois, a condenação de todos os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Deste modo, presente a tipicidade delitiva com relação ao crime de tráfico e ausentes justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e/ou a culpabilidade dos acusados, a imposição de sanção penal é medida que se impõe para concretizar os escopos de prevenção geral e especial colimados pela dogmática punitiva, além de ratificar a vigência da norma penal transgredida restabelecendo o princípio da prevalência do Direito.

Passo a dosar a pena.

De plano, destaco que "(...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...)." (STF, RHC 105921, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016). No mesmo sentido: STJ, HC 333.860/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016.

Na PRIMEIRA FASE, verifico que a quantidade de droga apreendida enseja o aumento de pena. Dessa forma, de acordo com o art. 59 do CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, não há agravantes nem atenuantes. Nenhum dos réus confessou, dois deles alegaram porte para uso pessoal e o terceiro negou os fatos.

Na TERCEIRA FASE, não há como se aplicar a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º ao artigo 33, da Lei n. 11.343/06, em que pese a primariedade e bons antecedentes dos acusados. Com efeito, de acordo com os C. STJ e STF, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.

(...) III - Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência (precedentes). (...) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015) (...) 4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. (...). 5. Ordem denegada. (STJ, HC 127221, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015)

E, enquanto a primariedade e os bons antecedentes são fatores objetivos, apurados a partir da Folha de Antecedentes do réu, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração de organização criminosa, por seu turno, são examinadas com base (i) na quantidade e/ou variedade e/ou nocividade da(s) droga(s) apreendida(s); (ii) na própria Folha de Antecedentes; (iii) no modo/forma de acondicionamento da(s) droga(s); (iv) no próprio modus operandi do tráfico de drogas; (v) na conduta social do(s) réu(s); (vi) nos instrumentos destinados ao tráfico de drogas (balança, anotações de contabilidade, armas, pinos, sacos para dosagem etc.) eventualmente apreendidos; (vii) no concurso eventual de agentes; (viii) na apreensão de expressiva quantidade de dinheiro associada à ausência de comprovação de atividade lícita ou apreensão de dinheiro em notas miúdas; (ix) no local da abordagem; (x) ausência de ocupação lícita. Conferir:

(...) 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa” (RHC nº 116.926/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/9/13). 5. Não se constata ilegalidade flagrante na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão aplicada ao paciente, pois essa tem por base, como se verifica no acórdão da apelação, as condições subjetivas valoradas negativamente. 6. A quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao paciente torna prejudicada, por si só, a pretendida substituição por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). 7. Habeas corpus denegado. (STF, HC 127241, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015 destaque adicionado)

(...) 2. Na espécie, os fatos que ensejaram a não-aplicação da causa de diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos (quantidade da droga e forma de acondicionamento) são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Recorrente às atividades criminosas. 3. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. 4. O habeas corpus não é prestante para revisar os elementos de prova invocados pelas instâncias de mérito a refutar a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao qual se nega provimento. (STF, RHC 94806, Relator(a): Min. CÂRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09/03/2010, DJe-067 DIVULG 15-04-2010 PUBLIC 16-04-2010 EMENT VOL-02397-02 PP-00785 destaque adicionado)

Ademais, a “(...) primariedade e os bons antecedentes não são suficientes ao deferimento do benefício, pois, nos termos do que contido no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a aplicação da redução da pena depende, ainda, de que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, (...)” (STF, HC 98366, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-022 DIVULG 04-02-2010 PUBLIC 05-02-2010 EMENT VOL-02388-01 PP-00192).

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já considerou como quantidades

indicadoras de dedicação à atividade criminosa os seguintes parâmetros: a) "(...)" 4. A quantidade e natureza das drogas apreendidas (in casu, 18,5 g de maconha e 14,8 g de cocaína, sendo parte na forma de crack), por indicar dedicação a atividades criminosas, pode embasar o não reconhecimento do tráfico privilegiado. (...)." (STJ, HC 326.519/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 03/08/2016 destaque adicionado); b) "(...)" 2. Os fundamentos utilizados pela Corte Estadual para não aplicar ao caso concreto a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, evidenciada sobretudo pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (7,4g de maconha, acondicionadas em 3 invólucros plásticos; 39,8g de "crack", acondicionadas em 117 invólucros plásticos; e 32g de cocaína, acondicionadas em 64 papелotes), está em consonância com o entendimento desta Corte. (...)." (STJ, HC 322.661/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016 destaque adicionado); c) "(...)" 2. Os fundamentos utilizados pela Corte Estadual para não aplicar ao caso concreto a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, evidenciada sobretudo pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (22 cápsulas de cocaína, pesando 18,87g, 21 invólucros de "crack", pesando 12,9g, e 21 invólucros de 'maconha', pesando 21,71g), está em consonância com o entendimento desta Corte. (...)." (STJ, HC 296.548/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016); (d) "(...)" Hipótese em que o Tribunal de origem conferiu legalidade à manutenção do não reconhecimento do privilégio, ao fundamentar que a quantidade, a variedade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos (15,13 gramas de cocaína e 26,23 gramas de crack), aliadas às circunstâncias em que o delito ocorreu, permitem concluir que o acusado dedica-se a atividades criminosas. (...)." (STJ, HC 362.266/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016 destaque adicionado); (e) "(...)" - À luz da jurisprudência desta Corte, é de ser mantido o afastamento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão fundamenta-se na quantidade e na variedade das drogas apreendidas, quais sejam, 42 porções de cocaína, com peso de 26,87g; 05 porções de maconha, com peso de 9,54g; e 14 porções de crack, com peso de 6,43g, circunstâncias aptas a indicar que o paciente dedicava-se a atividades ilícitas, a embasarem o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. (...)." (STJ, HC 301.828/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015 destaque adicionado).

Por sua vez, aquele mesmo Colendo Tribunal já apontou como quantidades que autorizam a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06: (i) "(...)" - No caso, sendo o paciente primário e tendo em vista a pequena quantidade da droga apreendida, qual seja, 5 gramas de crack, não há elementos concretos a indicar, juntamente com as circunstâncias do delito, que integre organização criminosa ou dedique-se às atividades ilícitas. (...)." (STJ, HC 364.447/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 26/09/2016 destaque adicionado); (ii) "(...)" - Não há como manter a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, que afastou a figura do tráfico privilegiado sob a tese de que o paciente dedica-se às atividades criminosas pelo fato de não exercer atividade lícita, pois estava desempregado à época dos fatos. Ademais, a quantidade da droga apreendida - 2,71g de cocaína -, apesar de nociva, não foi tão elevada a ponto de indicar, juntamente com as circunstâncias em que ocorreu o delito, a dedicação do acusado às atividades criminosas. (...)." (STJ, HC 336.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016 destaque adicionado); (iii) "(...)" - Não há como manter a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, que afastou a figura do tráfico privilegiado sob a tese de que os pacientes dedicam-se às atividades criminosas pelo fato de não exercerem atividade lícita, pois estavam desempregados à época dos fatos. Ademais, a quantidade da droga apreendida (13 cápsulas de cocaína, pesando 9,9 gramas), apesar de nociva, não foi tão elevada a ponto de indicar, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação dos acusados às atividades ilícitas. (...)." (STJ, HC 336.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016 destaque adicionado).

(STJ, HC 313.899/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016 destaque adicionado); (iv) "(...) 6. Nem mesmo a quantidade de drogas apreendidas - admitida por esta Corte como fundamento idôneo para justificar a recusa da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 - autorizaria tal negativa no caso concreto, que cuida de tráfico de 0,9 g de crack." (STJ, REsp 1434029/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015 destaque adicionado). Nesse contexto, inaplicável a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), considerando que apesar da primariedade, a grande quantidade de drogas transportadas (03 invólucros de maconha, pesando 992,2 gramas), evidencia que não se tratavam de traficantes amadores, que possuíam acesso a grandes fornecedores e se dedicavam às atividades criminosas. Além disso, as conversas degravadas, embora não sejam suficientes para comprovar a prática da associação do artigo 35, mostram o envolvimento dos réus com o crime organizado e a dedicação a atividades criminosas, ainda que de forma esparsa.

Tem-se a pena final de: 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Valor da Pena de Multa

O dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto no artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Regime de Cumprimento de Pena - Substituição de Pena - "Sursis"

Em observância aos arts. 33 e 59, do Código Penal, e ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, e notadamente às peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (a ausência de emprego formal, o que indica que fazem do crime seu meio de vida, gravidade do crime a que foram condenados, além do quantum da pena aplicada), fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena. Por seu turno, ausentes os requisitos, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (art. 77 CP) ou substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal). De fato, a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos.

III - Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

a) ABSOLVER os acusados EVERTON RODOLFO RODRIGUES, MATEUS RODRIGUES FRANCISCO e PAULO SÉRGIO DESTEFANI FILHO da prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e  
b) CONDENAR os réus EVERTON RODOLFO RODRIGUES, MATEUS RODRIGUES FRANCISCO e PAULO SÉRGIO DESTEFANI FILHO à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, cada um fixado em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, dando-os como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal

Apesar do disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, o período da prisão provisória não altera o regime inicial aplicado, conforme intervalos delimitados pelo art. 33, § 2º, do Código Penal. Ademais, já foi consignado por diversas Colendas Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça a impossibilidade, em regra, do juízo de conhecimento examinar todos os requisitos (objetivos e subjetivos) para aplicação do § 2º do art. 387 do CPP.

Por derradeiro, não há como se efetuar a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal com as alterações trazidas pela Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, eis que não há nos autos informes sobre eventual comportamento carcerário dos réus, ou existência de demais processos, sendo que a solicitação de apresentação de informações ao Juízo competente postergaria o desfecho dos autos. (TJSP, Apelação nº 0086558-34.2014.8.26.0050, Relator(a): Silmar Fernandes; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal Extraordinária; j: 13/04/2016; Data de registro: 17/04/2016).

"Note-se que, a despeito da redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, modificada pela Lei nº 12.736/12, não fazem jus os apelantes à imposição, diretamente pela r. sentença de primeiro grau, do regime aberto ou semiaberto, em

razão da detração para fins de regime prisional, pois ausentes elementos suficientes nos autos para sua concessão. Para tal fim, impor-se-ia a análise da presença de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o subjetivo, que é verificável apenas perante o Juízo das Execuções Criminais, responsável por dirigir e fiscalizar o cumprimento da pena." (TJSP, Apelação nº 3001370-97.2013.8.26.0586, Relator(a): Toloza Neto; Comarca: São Roque; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro: 12/04/2016)

No mesmo sentido: TJSP, Apelação nº 0014589-90.2013.8.26.0050, Relator(a): Fernando Simão; Comarca